

114年公務人員特種考試司法官考試第二試
114年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試
法律專業科目評分要點與閱卷委員的話

科目：刑法與刑事訴訟法

第一題

【總題說明】

本題旨在測驗刑法總則歸責理論與分則構成要件解釋之綜合運用能力。題旨涵蓋國家、社會及個人法益，評分重點在於應考人能否就關鍵構成要件要素及複雜歸責問題進行深入剖析與論證。文字是否清晰、論理是否一貫、是否掌握學說與實務見解、是否有個人見解，皆為關鍵評分依據。

【評分要點】

甲之刑事責任

壹、甲承諾推薦A之子進入企業工作，可能構成刑法第144條之罪

一、構成要件該當性

本罪之構成要件為對於有投票權之人，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使。期約係指當事人就特定事項達於意思一致，不以實際給予賄賂或不正利益為必要。甲承諾於未來當選後將推薦A之子工作，該當本罪「期約」要素，其與A之投票權行使亦有對價關係。問題在於，甲承諾當選後將推薦A之子工作，是否屬於本罪的「不正利益」？

1. 肯定說認為，不正利益是指賄賂以外，一切足以供人需要或滿足慾望之有形或無形利益。使人得到工作機會，客觀上具有經濟價值，主觀上亦能滿足人的慾望，故該當不正利益。
2. 否定說認為，「推薦」不代表必然獲得職位，此種利益具有高度不確定性；且獲得工作後須付出勞力始能賺取薪資，薪資並非投票的代價，故不應視為不正利益。
3. 個人見解。

二、違法性與罪責（採肯定說時）

無阻卻違法事由且無阻卻或減免罪責事由。

三、結論

貳、甲回覆乙支持其想法，可能構成刑法第 315 條之 1 第 2 款之罪、刑法第 319 條之 1 第 3 項之罪之教唆犯、精神幫助犯或共同正犯

一、構成要件該當性

若肯定乙成立刑法第 315 條之 1 第 2 款之罪、刑法第 319 條之 1 第 3 項之罪，甲回覆「我支持你的想法」，既非使乙從無到有產生犯罪意思之造意行為，亦未曾與乙共同進行犯罪謀議，僅在精神上施予乙助力，成立精神幫助犯。

二、違法性與罪責

無阻卻違法事由且無阻卻或減免罪責事由。

三、結論

參、甲利用電腦軟體合成丙、丁之影音檔與虛假性影像，可能構成刑法第 319 條之 4 第 1 項之罪

一、構成要件該當性

本罪之構成要件，為意圖散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽，以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實之性影像，足以生損害於他人。甲意圖於選前之夜散布，而以電腦將僅有聲音與車子震動影片的影音檔，與虛假性影像合成為丙、丁之性交影片，該當本罪構成要件。

二、違法性與罪責

無阻卻違法事由且無阻卻或減免罪責事由。

三、結論

甲構成本罪。

肆、甲利用電腦軟體合成丙、丁之影音檔與虛假性影像，可能構成刑法第 235 條第 2 項之罪

一、構成要件該當性

本罪之構成要件，為意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品。甲意圖於選前之夜散布，而以電腦軟體合成丙、丁之虛假性交影片，係製造猥褻影像無誤，該當本罪構成要件。

二、違法性與罪責

無阻卻違法事由且無阻卻或減免罪責事由。

三、結論

甲構成本罪。

伍、競合

甲合成性影像之行為，同時該當刑法第 319 條之 4 第 1 項與刑法第 235 條第 2 項之罪，為想像競合，應從一重處斷。此罪與甲另犯之三罪，應予分論併罰。

乙之刑事責任

壹、乙錄下丙、丁性交聲音與汽車震動，可能構成刑法第 315 條之 1 第 2 款之罪

一、構成要件該當性

本罪之構成要件，為無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位。乙未得丙、丁同意而以手機錄影、錄音，屬於本罪竊錄。問題在於乙是否竊錄丙、丁之「非公開活動」？

1. 肯定說認為，汽車雖停放於公共空間，但丙、丁是在汽車封閉空間內為性交行為，主觀上有不為人知的意思，客觀上亦與外界有所區隔，具有不受他人紀錄之合理隱私期待。
2. 否定說認為，乙錄下的汽車震動畫面與性交聲音，並非侷限在汽車封閉空間內，而已展露於外，經過該處的路人皆可輕易察覺，客觀上難謂已採取隔絕措施充分確保活動的隱密性，故丙、丁對此不具合理隱私期待。
3. 個人見解。

二、違法性與罪責（採肯定說時）

無阻卻違法事由且無阻卻或減免罪責事由。

三、結論

貳、乙錄下丙、丁性交聲音與汽車震動，可能構成刑法第 319 之 1 第 3 項之罪

一、構成要件該當性

本罪之構成要件，為未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像。問題在於，以丙、丁性交聲音與汽車震動為內容的錄影，是否為本罪之「性影像」？

1. 否定說認為，從罪刑法定主義的角度，性影像須具視覺性，應直接以性行為實況或身體隱私部位實體為內容。以車震畫面及性交聲音為內容之錄影，視覺上並未裸露身體部位或展現性動作，雖可間接推知當事人正在進行性行為，亦非屬本罪之性影像。
2. 肯定說認為，從保護性隱私的角度，性交聲音結合車震畫面，已可充分傳達丙、丁性交之訊息，且因攝錄內容包含丙呼喊丁的名字而可識別被害人身分，其對當事人之性隱私侵害，實與直接拍攝裸露畫面無異，從而至少可認定為刑法第 10 條第 8 項第 4 款「其他與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之行為」。
3. 個人見解

二、違法性與罪責（採肯定說時）

無阻卻違法事由且無阻卻或減免罪責事由。

三、結論

參、乙將影音檔傳給甲，可能構成刑法第 319 之 3 第 2 項之罪

一、構成要件該當性

本罪之構成要件，為未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像，且其性影像係第三百十九條之一第一項至第三項攝錄之內容。倘若肯定乙所攝錄者屬於性影像，則其將影音檔傳送給甲，構成本罪所稱未經同意而「交付」犯刑法第 319 之 1 第 3 項之罪而攝錄之性影像，該當本罪構成要件。

二、違法性與罪責（採肯定說時）

無阻卻違法事由且無阻卻或減免罪責事由。

三、結論

肆、競合

若認為刑法第 315 條之 1 第 2 款之罪與刑法第 319 之 1 第 3 項之罪成立法條競合，則僅論以後者之罪。又刑法第 319 之 1 第 3 項之罪與刑法第 319 之 3 第 2 項之罪成立與罰的前行為，僅論以後者之罪。若認為刑法第 315 條之 1 第 2 款之罪與刑法第 319 之 1 第 3 項之罪，因保護法益不同而成立想像競合，第 319 之 1 第 3 項之罪又為刑法第 319 之 3 第 2 項之罪的與罰前行為，則刑法第 315 條之 1 第 2 款之罪，應與刑法第 319 之 3 第 2 項之罪分論併罰。

丙之刑事責任

壹、丙撞擊 B，可能構成刑法第 271 條第 1 項或第 2 項之罪

一、構成要件該當性

本罪之構成要件，為基於殺人故意而創造針對他人之非容許生命風險，且該風險實現成死亡結果。丙在「明知」可能會撞到用路人下超速行車，所謂「撞到用路人」意味著非死即傷，故丙係基於殺人故意而創造針對 B 的非容許生命風險。問題在於，該風險是否實現成 B 的死亡結果？

1. 否定說認為，丙撞傷 B 後離去，又折回現場掩埋 B 導致其死亡，係影響風險流程正常實現之事實，B 的死亡客觀上不可歸責給丙的撞擊行為。
2. 肯定說認為，上開事實介入符合一般經驗，不影響行為與結果之間的常態關聯性，結果客觀上可歸責給丙的撞擊行為。
3. 個人見解。

若採肯定說，則進入「雙行為因果歷程錯誤」的問題，學說上有概括故意說、自主雙行為、第一行為關鍵說、第二行為修正說等不同見解。

1. 概括故意說將撞擊行為與掩埋行為視為一個連續的整體過程，丙自始即有殺害 B 的故意，儘管 B 的死亡結果發生在第二階段，但兩個行為都在丙的概括殺人故意範圍內，不影響故意殺人罪之成立。
2. 自主雙行為說認為，撞擊行為與掩埋行為為獨立的兩個行為，丙僅有在撞擊行為時具有殺 B 的故意，在掩埋行為時誤認 B 為屍體，頂多成立過失致死。
3. 第一行為關鍵說主張，只要撞擊行為創造的因果歷程正常實現，掩埋行為的介入僅是不具重要性的輕微偏離，即不妨礙故意殺人罪之成立。
4. 第二行為修正說主張，依個案事實，若認為丙在掩埋 B 時發覺 B 未死，仍會有殺 B 的故意，即無礙於故意殺人罪的成立。否則，掩埋行為至多構成過失致死。
5. 個人見解。

二、違法性與罪責（採肯定說時）

無阻卻違法事由且無阻卻或減免罪責事由。

三、結論

貳、丙未救援 B，可能構成刑法第 15 條第 2 項、刑法第 271 條第 1 項不純正不作為殺人罪

一、構成要件該當性

本罪之構成要件，為具有保證人地位者基於殺人故意不施以救援，以致被害人死亡。問題在於，丙故意撞擊 B 後不施以救援而離去，丙是否具有保證人地位？

1. 否定說認為，故意危險前行為不構成保證人地位，一方面意在避免雙重評價，因後續侵害結果已可歸責給故意危險前行為，而構成一個完整的故意作為犯；另一方面，要求故意犯罪者救援被害人，實欠缺期待可能性。
2. 肯定說認為，故意行為後若結果尚未發生，此時要求行為人救援法益仍有實益，亦為刑法保護法益誠命的體現；而且行為人自身亦掌握消滅風險的關鍵性地位。
3. 個人見解。

二、違法性及罪責（採肯定說時）

無阻卻違法事由且無阻卻或減免罪責事由。

三、結論

參、丙掩埋 B 致其死亡，可能構成刑法第 276 條之罪

一、構成要件該當性

本罪之構成要件，為違反客觀注意義務而創造針對他人之非容許生命風險，且該風險實現成死亡結果。倘若認為 B 的死亡不可歸責給丙的撞擊行為，則丙未仔細確認 B 的生命跡象，即誤認 B 已死而加以掩埋，係違反客觀注意義務而創造針對 B 的非容許生命風險，該風險亦實現成 B 的死亡結果，該當本罪。

二、違法性及罪責（採肯定說時）

無阻卻違法事由且無阻卻或減免罪責事由。

三、結論

肆、丙掩埋 B，可能構成刑法第 247 條第 1 項之罪

一、構成要件該當性

本罪之構成要件為損壞、遺棄、污辱或盜取屍體。丙掩埋 B 時其尚未死亡，並非本罪所稱「屍體」，不該當本罪要件。

二、結論

丙不構成本罪。

伍、丙逃離現場，可能構成刑法第 185 條之 4 第 1 項之罪

一、構成要件該當性

本罪之構成要件，為駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害、致人於死或重傷而逃逸。問題在於，丙係「故意」駕車撞擊 B 後逃離現場，是否仍構成本罪？

1. 肯定說認為，即使為故意製造交通事故，仍有要求行為人停留現場施以救援及釐清責任之實益。
2. 否定說認為，故意製造交通事故時要求行為人不離開現場，缺乏期待可能性。
3. 個人見解。

二、違法性及罪責（採肯定說時）

無阻卻違法事由且無阻卻或減免罪責事由。

三、結論

陸、競合

若認為丙就 B 死亡僅成立刑法第 271 條第 1 項之罪，則該罪與刑法第 185 條之 4 第 1 項之罪數罪併罰。若認為丙就 B 死亡僅成立刑法第 276 條之罪，則其亦與刑法第 185 條之 4 第 1 項之罪數罪併罰。

丁之刑事責任

壹、丁不斷催促丙開快一點，可能構成刑法第 276 條之罪

一、構成要件該當性

本罪之構成要件，為違反客觀注意義務而創造針對他人之非容許生命風險，且該風險實現成死亡結果。丁不斷催促丙開快一點，等於要求丙超速行駛，係創造針對 B 的非容許生命風險，但該風險是否實現成 B 的死亡結果？問題有二。第一個問題是，丙係故意撞擊 B，是否適用「回溯禁止」概念而阻斷丁的歸責關係？

1. 否定說認為，故意行為人介入因果流程並不影響前行為人的歸責關係，關鍵在於風險是否正常實現。
2. 肯定說認為，前行為人只為自己的行為負責，而不為他人的故意行為負責，故 B 之死亡結果不可歸責給丁。
3. 個人見解。

第二個問題是，若否定回溯禁止概念，則必須討論，後續丙掩埋 B 致其死亡的事實，是否為影響丁創造之風險常態實現的反常因素？亦有肯否兩說。

二、違法性及罪責（採否定說時）

無阻卻違法事由且無阻卻或減免罪責事由。

三、結論

貳、丁催促丙開快一點，可能構成刑法第 284 條之罪

一、構成要件該當性

本罪之構成要件，為創造針對他人之非容許身體風險，且該風險實現成傷害結果。若否定回溯禁止概念，且否定 B 死亡與丁行為之間的客觀歸責關係，則 B 被丙撞擊而受傷的結果仍可歸責給丁，構成本罪。

二、違法性及罪責

無阻卻違法事由且無阻卻或減免罪責事由。

三、結論

參、丁未救援 B，可能構成刑法第 15 條第 2 項、刑法第 271 條第 1 項不純正不作為殺人罪或刑法第 271 條第 2 項不純正不作為殺人未遂罪

一、構成要件該當性

本罪之構成要件，為具有保證人地位者基於殺人故意不施以救援，以致被害人死亡。丁不斷催促丙超速，為過失危險前行為，導致丙撞傷 B 後，具有救援 B 的保證人地位，縱然認知不救援 B 將會死亡，仍逃逸未施以救援，放任 B 的生命風險實現。問題在於，B 最終死亡結果是否為丁放任之風險的典型實現？肯、否見解參見前述。

二、違法性及罪責（採肯定說時）

無阻卻違法事由且無阻卻或減免罪責事由。

三、結論

肆、競合

丁就 B 死亡可能僅構成刑法第 276 條之罪、刑法第 271 條第 1 項之罪，或刑法第 271 條第 2 項之罪其中之一，此時不另論以他罪。

【閱卷委員的話】

- 一、本題需要論斷的行為人甚多且犯罪事實互相關聯，導致爭點亦較為複雜。在解題架構上可以發現多數考生都能維持以行為為論斷中心，並以三階為主軸的架構進行分層次的論述，但除了架構以外還需要注意實質的爭點，如果僅列出架構，對於題目真正的爭點卻輕輕帶過甚至忽略，不免有徒具其形，未見其神之憾，如不乏有認定行為人不成立某罪後，即結束作答的試卷，但不成立某犯罪不代表也不成立其它犯罪，如果只認定不成立某罪即下結論，可能就有爭點分析不夠完整的問題。另外也要注意行為之間的關係與其對應的法律評價。如有試卷在檢討丙的罪責時，只檢討肇事逃逸的問題。但由於丙之前就因車速過快撞上 B，這部分行為的評價無法被肇事逃逸所包含，故僅針對肇事逃逸進行分析也會導致法律爭點的評價不完整，進而發生對於行為人之行為的法律評價不足的狀況。
- 二、與此相對的，閱卷時也發現部分試卷有討論過於發散的問題。如賄選的部分，部分試卷大費周章地確認不管採取法定職務說、職務關連性或實質影響力說，結論都是不構成第 123 條，接著再討論第 144 條的問題。惟依照本題事實，甲和 A 約定乃是甲作為企業家身分所能影響的內容，這一點就可以確認其約定的事項一開始就和公務員的職務無任何關聯性，故這部分是否有必要作為爭點討論，容有商榷之餘地。因此在分析本題的爭點時，必須要依照事實關係進行討論，若忽略此點，可能反而會導致作答過度發散而無法及時作答完畢。
- 三、另外由於本題事實複雜，也影響到對於某一行為的法律評價可能會造成後續的連鎖反應問題。如關於丙的罪責，如果無法認定撞上 B 的行為有殺人的未必故意，後續就難以討論 B 的死亡是否有數行為因果歷程錯誤的問題。此時可能就必須依對丙撞上 B 之行為如何評價，來決定後續的作答方向要往因果歷程的重大偏離，或是直接切開成數行為討論等。惟多數試卷雖然有發現可能有因果歷程錯誤的問題，但由於對撞上 B 的行為之評價有不同之處，故為了在試卷中回應因果歷程錯誤的問題，導致改以後續的不救助的不作為和遺棄的作為為主，並將其當作雙行為因果歷程錯誤的狀況進行分析。惟不作為會持續進行，就算中間有其它非履行救助義務的作為，仍不妨礙把不救助的行為評價為不作為。但此種不作為和作為發生重疊的狀況，是否適合使用雙行為因果歷程錯誤來解釋，此點亦容有爭議。若忽略

此點，直接將雙行為因果歷程錯誤的討論套入上述情形進行討論，不免讓人有削足適履之感。

四、另外實務判決的引用雖然亦佔有重要之地位，但也必須注意引用之實務判決對於爭點處理的作用。如有部分試卷引用認為肇事逃逸為己手犯的實務判決，並以之說明非己手實行之人不成立犯罪。但由於己手犯僅影響非己手實行之人不成立正犯，其人仍有成立幫助犯和教唆犯之可能性，故僅以上述判決證明非己手實行之人不成立正犯，可能會發生引喻失義的問題。

第二題

【總題說明】

本題分為三子題，題幹敘述從偵查程序直到上訴審，所涉爭點有強制處分、緩起訴和上訴利益審查、第三人沒收程序，各項爭點均有學說探討與實務見解，均非刑事訴訟法冷僻議題。各子題命題構想之爭點，依序為：

- 一、強制處分：刑法犯罪所得認定（刑法 38-1）、證據扣押和犯罪所得扣押（刑訴 133 I, 133-1 I），相關實務見解如 111 台上 1345。
- 二、上訴利益與第三人沒收程序：上訴利益屬上訴合法要件（刑訴 362、367），無罪併監護處分判決之上訴具有上訴利益，相關實務如 106 刑議 9、107 台上 2017。法院職權裁定命第三人參與沒收程序，參見 108 台上大 3594。
- 三、緩起訴：緩起訴撤銷事由（刑訴 253-3 I (1)）、不受理判決事由（刑訴 303(1), (4)），實務見解為 103 台上 3183、105 台非 52、106 台非 209。

【評分要點】

第(一)子題

本件扣押合法。說明如下：

1、扣押實體要件（扣押原因）

依第 133 條第 1 項規定「可為證據或得沒收之物，得扣押之」，此屬扣押之實體要件規定，表達刑事訴訟之法定扣押原因。據此，扣押原因可分為「證據扣押」與「保全沒收之扣押」（學理區分，實務見解參見 105 台抗 382）。系爭名牌包是可證明甲竊盜罪之證據，又是甲竊盜之犯罪所得（參見刑法第 38 條

之 1 第 1 項），從而，扣押系爭名牌包，同時具有「證據扣押」和「保全沒收扣押」之扣押原因。

2、非附隨於搜索之扣押程序要件

本件雖具備扣押原因，仍應進一步判斷扣押程序要件。扣押程序依是否附隨於搜索，區分成應依搜索規定或獨立扣押規定（參見第 133 條之 1 第 1 項）。

依題示，丙認出甲走向醫院停車場的一部汽車後座睡覺，該車四面車門大開，丙一眼發現名牌包被放置在汽車駕駛座上，迅速扣押名牌包，可知本件扣押並非附隨於搜索所發現，故屬非附隨於搜索之扣押。因此，後續扣押程序應依非附隨於搜索之扣押的程序要件審查。另補充，丙先扣押再喚醒甲並予以逮捕，過程並無搜索行為，更與附帶搜索規定先逮捕再搜索、扣押的順序不同（第 130 條），附帶搜索不得作為本件扣押之法律依據。

3、無令狀扣押：同意扣押、證據扣押

非附隨於搜索之扣押，其程序要件上，除證據扣押、同意扣押和緊急扣押外，應事先取得法官之扣押裁定（參見第 133 條之 1、第 133 條之 2 第 3 項）。應注意，第 133 條之 1 立法理由表示「同時得為證據及得沒收之物，仍應經法官裁定，以免架空就沒收之物採法官保留為原則之立法意旨」，因此，扣押僅在純屬證據扣押之原因時，始不經法官扣押裁定，倘同時具備證據扣押與保全沒收之扣押者，仍應事先取得扣押裁定。另從學理而言，證據扣押與保全沒收之扣押，既然扣押原因有異，扣押程序之設計自應不同，當兩者競合，應各有合法干預依據，不得擇一取代。故在學理理解下，單純之證據扣押在立法論上仍應有扣押裁定，並非因為同時涉及保全沒收之扣押始要求扣押裁定，上開立法理由之說法，值得商榷。

本案中，警察丙於扣押前並未取得法官扣押裁定，所以是無令狀之扣押。關於無令狀扣押之程序合法性判斷，可審查同意扣押、證據扣押與緊急扣押。首先，甲在睡覺，故無須考慮同意扣押（參見第 133 條之 1 第 2 項）的可適用性。又如前所述，系爭名牌包具備證據扣押和保全沒收扣押之扣押原因，故無法自始免除扣押裁定之要求。唯一可作為警察丙無令狀扣押的程序正當基礎者，僅剩緊急扣押。

4、緊急扣押

偵查機關於偵查中有相當理由認為情況急迫，有立即扣押之必要時，得逕行扣押，並應於執行後三日內報告該管檢察署檢察官及法院（參見第 133 條之 2

第 3、4 項)。

於本案，應以緊急扣押作為扣押依據，判斷是否存在情況急迫。申言之，如不予當場扣押，而向法院聲請令狀，聲請期間，易生被告清醒後攜帶應扣押物逃跑致證據滅失之高度疑慮，故應屬情況急迫；又警察當日有向檢察官及管轄法院報告扣押，符合事後陳報義務，符合緊急扣押規定。因此，本件屬於緊急扣押，扣押程序合法。是否構成情況急迫，依考生就題示情節說理詳細程度評分。

5、結論

警察丙扣押系爭名牌包，符合第 133 條第 1 項、第 133 條之 2 第 3、4 項緊急扣押規定，故扣押合法。

相關實務見解

111 台上 1345：搜索，除以人身為標的（即以發現應受拘提或逮捕之被告、犯罪嫌疑人所在為目的）之對人搜索外，以物品為標的之對物搜索，係指為發現應扣押之可為證據或得沒收之物為目的，而搜查檢索被告、犯罪嫌疑人或第三人之身體、物件、住宅或其他處所之強制處分。扣押，則係為取得物之占有而對其所有人、持有人或保管人所為之強制處分（至刑事訴訟法第 143 條所規定被告、犯罪嫌疑人或第三人遺留在犯罪現場之物，或所有人、持有人或保管人任意提出或交付之物，經留存者，雖準用物品扣押後處置之相關規定，然非屬強制扣押範疇）。扣押通常雖係緊隨於搜索之後而來，然亦有獨立於搜索程序外之扣押，其型態若從用途或目的觀察，可分為保全證據之扣押與保全沒收或追徵之扣押；若從手段或方式觀察，則可分為附隨於搜索之扣押與非附隨於搜索之單獨或獨立扣押。關於非附隨於搜索之單獨或獨立扣押，觀諸刑事訴訟法第 133 條之 1 第 1 項規定非附隨於搜索之單純證據保全扣押、經受扣押標的權利人同意之扣押，以及同法第 133 條之 2 第 3 項規定有相當理由認為情況急迫而有立即扣押必要所為之逕行扣押（下或從學理名為「緊急扣押」稱之）等情形即明。是搜索與扣押，本為二種性質不同之強制處分，其所干預之人民基本權亦不盡相同（搜索涉及人身自由、住居隱私及財產等權利；扣押則僅涉及財產權利），並各有其適法性之判斷準據。茲對於可為證據或得沒收之物，苟係依上述刑事訴訟法第 133 條之 2 規定所為非附隨於搜索之緊急扣押，即有其執行之法律依據，而難謂係非法扣押。再上述因緊急扣押而取得之證據，既非經搜索查

獲，則其有無證據能力之判斷，即與搜索違法與否無關，更與被告或犯罪嫌疑人是否先經依法逮捕，而得依同法第 130 條關於司法警察（官）逮捕被告或犯罪嫌疑人時，雖無搜索票，得逕行搜索其身體、隨身攜帶之物件、所使用之交通工具及其立即可觸及之處所（下或稱逮捕時附帶逕行搜索）之規定不相干涉。至倘係經無令狀搜索而發現並扣押之證據，因屬附隨於搜索之扣押，其扣押合法與否暨所取得之證據有無證據能力，取決於搜索之適法性。苟搜索程序不合法，則附隨在後所扣押之證據，應依刑事訴訟法第 158 條之 4 規定以資權衡論斷其證據能力之有無；但若搜索係依法律規定之程序而為，並據此扣押可為證據或得沒收之物，自不得謂該等查扣物品係違法搜索扣押之證據而無證據能力。

第(二)子題

1、甲有上訴利益，上訴合法。說明如下：

(1) 上訴利益之意義與欠缺之法律效果

被告上訴應有上訴利益，亦即，以其受有不利益之判決，為求自己利益起見請求救濟者，始得為之。上訴若欠缺上訴利益，乃上訴不合法，二審法院應以判決駁回上訴（參見第 367 條前段、第 362 條前段）。實務見解，如 71 台上 1423(判例)：「刑事被告之上訴，以受有不利益之判決，為求自己利益起見請求救濟者，始得為之，原審認屬罪名較輕之竊盜，上訴人主張為較重之搶奪，顯於為自己利益請求救濟之旨相違，其上訴自非合法，應予駁回。」

(2) 無罪判決同時諭知監護處分者，被告有上訴利益

本案中，甲受無罪判決，但同時被諭知施以監護處分，依第 348 條第 3 項「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，甲雖得僅就監護處分上訴，但一部上訴之合法性與否，仍應通過上訴利益審查。從人身自由保護的立場觀之，受監護處分之被告，其有受人身拘束不利益效果，此與僅單純宣告無罪之判決不同。實務見解亦同，106 刑議 9：「原審無罪判決，已同時諭知對被告不利之監護處分，而與僅單純宣告被告無罪之判決不同，自應認被告具有上訴利益，不得逕以其無上訴利益而予駁回」。

(3) 結論

依學理與今日實務的共同見解，甲之上訴應認具有上訴利益，二審法院不得以上訴不合法駁回。

2、法院應依職權裁定命丁參與沒收程序

(1) 第三人沒收程序

不知情之第三人丁，以遠低於市場二手行情價格向被告甲購入被搶奪之名錶，依刑法第 38 條之 1 第 2 項第 1 款「因他人違法而無償或以顯不相當之對價取得」，法院仍應向第三人丁諭知沒收該名錶。對應於刑事訴訟法，則應賦予丁參與第三人沒收程序之機會（刑訴第 455 條之 12 以下規定），以保障其聽審權及救濟權。

(2) 法院依職權裁定開啟沒收程序

有疑問者，本案檢察官並未向法院聲請沒收名錶，法院是否不得開啟第三人沒收程序？現行實務認為第三人沒收程序之開啟，不以檢察官聲請為必要。依最高法院刑事大法庭見解與學說見解，法院依第 455 條之 12 第 3 項前段裁定命第三人參與沒收程序，並依審理結果，諭知沒收與否之判決，不以經檢察官聲請為必要（108 台上大 3594）。惟有部分文獻持不同意見，認為法院依職權裁定命丁參與沒收程序，違反控訴原則。

(3) 結論

本案中，檢察官雖未聲請沒收系爭名錶，二審法院仍認有宣告沒收之可能者，應依職權裁定命丁參與沒收程序，二審審理後諭知沒收系爭名錶，該沒收判決並無不當。

相關實務見解

108 台上 1061：按刑事被告之上訴，以因受有不利益之裁判，而為求自己利益起見，請求上級法院救濟者，方得為之，此乃上訴制度設計之本旨，從反面而言，無許其為自己之不利益，作為上訴之理由，學理上稱為「無利益即無上訴」原則。然而，被告受無罪之諭知，縱屬對其最有利之判決，但因刑事訴訟法第 301 條第 1 項規定，被告受無罪之判決，可分為「不能證明被告犯罪」與「行為不罰」二種情形。前者係指無法以證據證明被告有被訴之犯罪，乃基於事實理由，而認定被告無罪；後者則指起訴事實雖經證明，但法律上並不處罰其行為，乃出於法律理由，而諭知被告無罪。而行為不罰者，如係因具有阻卻責任性之事由，例如具有刑法第 19 條第 1 項所定因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識行為違法，或欠缺依其辨識而行為之能力之原因而不罰情形存在，固應受無罪諭知。惟同法第 87 條另規定：「因同法第 19 條第 1 項之原因而不罰者，其

情狀足認有再犯或有危害公共安全之虞時，令入相當處所施以監護，其期間為5年以下。」即屬學理上所稱監護處分之保安處分，乃出於防衛社會與預防再犯之目的，對受處分人施加治療之制裁措施，以期回歸社會，具有替代刑罰之作用，並有拘束身體、自由等之處置；尤以對精神障礙者之監護處分，依保安處分執行法第47條規定：「受執行監護之精神病院、醫院，對於因有刑法第19條第1項或第2項之情形，而受監護處分者，應分別情形，注意治療及監視其行動」，從而，此就人身自由的立場而言，仍屬對被告不利之處分。具體以言，法院就此類被告之行為，依刑事訴訟法第301條為無罪之諭知時，猶應斟酌其情狀為監護處分及期間之諭知。是以，此項監護處分與無罪之諭知，具有不可分離之關係，不能割裂為二事；其有無上訴利益，必須為整體之觀察，無從分別判斷，為本院近年來一致之見解。

108 台上大 3594：對第三人財產之沒收，乃刑法所明定，檢察官對特定被告及犯罪事實起訴之效力，涵括對被告及第三人沒收之法律效果，法院審理結果，認被告犯罪或有違法行為，且符合依法沒收之要件者，即有諭知沒收之義務，尚無待檢察官之聲請。從而，如涉及第三人財產之沒收，而檢察官未於起訴書記載應沒收第三人財產之意旨，審理中，第三人亦未聲請參與沒收程序，檢察官復未聲請者，法院為維護公平正義及保障第三人之聽審權，基於法治國訴訟照料義務之法理，認為有必要時，應依刑事訴訟法第455條之12第3項前段規定，本於職權，裁定命該第三人參與沒收程序，並依審理結果，而為沒收與否之判決。

第(三)子題

第一審法院應依第303條第1款為不受理判決。說明如下：

1、更犯他罪之緩起訴撤銷事由及其目的性限縮解釋

根據第253條之3第1項第1款規定，被告於緩起訴期間內，故意更犯有期徒刑以上刑之罪，經檢察官提起公訴者，檢察官得依職權撤銷原緩起訴處分，繼續偵查或起訴。按題旨，甲於案件1竊盜罪的緩起訴期間更犯案件2搶奪罪，並經檢察官B提起公訴，檢察官A似得依第253條之3第1項第1款，撤銷甲案件1之緩起訴。

然而，構成甲緩起訴撤銷事由的案件2之起訴，最終被判決無罪確定。此時是否仍應形式拘泥於該款文義而撤銷案件1的緩起訴，並非無疑。因此，值得採

納之觀點（如 103 台上 3183、105 台非 52、106 台非 209 等），乃是對第 253 條之 3 第 1 項第 1 款進行目的性限縮解釋，亦即，緩起訴期間更犯之罪，倘嗣經判決無罪確定，表示被告無違反犯罪特別預防目的之情事，如拘泥於該款規定得撤銷緩起訴處分之文字，而認緩起訴撤銷為合法，顯不符公平正義。據此，第 253 條之 3 第 1 項第 1 款宜為目的性限縮解釋，即被告更犯之罪，若經判決無罪確定，表示該撤銷緩起訴自始違法。

所以，甲於案件 1 緩起訴期間更犯故意搶奪罪並經起訴，但最終由於判決無罪確定，依第 253 條之 3 第 1 項第 1 款目的性限縮解釋的主張，即不認為成立該款事由，檢察官 A 撤銷案件 1 之緩起訴因此違法。

2、依第 303 條第 1 款為不受理判決

檢察官撤銷案件 1 之緩起訴，由於自始違法，依司法院釋字第 140 號解釋之同一法理，即與該緩起訴處分自始未經撤銷無異。此時，法院對檢察官就案件 1 所提起之公訴，應視起訴時該緩起訴處分期間已否屆滿，分別依第 303 條第 1 款起訴之程序違背規定，或同條第 4 款緩起訴期滿未經撤銷，而違背同法第 260 條之規定再行起訴，分別諭知不受理判決（參見 103 台上 3183、105 台非 52、106 台非 209 等）。

依題旨，案件 1 之緩起訴期間為 113 年 4 月 8 日起至 114 年 4 月 7 日，檢察官 A 於違法撤銷緩起訴後再行起訴的時點為 114 年 2 月 21 日，可知起訴時，緩起訴處分期間尚未屆滿。因此，對於案件 1 之起訴，第一審法院應依第 303 條第 1 款「起訴之程序違背規定」諭知不受理判決。

3、結論

檢察官撤銷緩起訴為違法，其再行起訴，第一審法院應依第 303 條第 1 款為不受理判決。

相關實務見解

103 台上 3183：刑事訴訟法第二百五十三條之三第一項第一款緩起訴處分之撤銷，雖僅規定於緩起訴期間內故意更犯有期徒刑以上刑之罪，經檢察官提起公訴者，檢察官得依職權或依告訴人之聲請為之，未明定被告更犯之罪經判刑確定為要件。然查，我國緩起訴制度係為使司法資源有效運用，填補被害人之損害、有利被告或犯罪嫌疑人之再社會化及犯罪之特別預防等目的，參考外國立法例，配合刑事訴訟制度採改良式當事人進行主義之起訴猶豫制度。倘上開更犯之罪，嗣

經判決無罪確定，表示被告無違反犯罪特別預防目的之情事，如拘泥於該款得撤銷緩起訴處分之文字規定，而認撤銷為合法，顯不符公平正義，無足以保障被告權益。基此，本院認為該款得撤銷緩起訴處分規定，宜為目的性限縮解釋。即被告更犯之罪，嗣經判刑確定，該撤銷固屬合法，但若經判決無罪確定，表示該撤銷自始存有重大瑕疵，係屬違誤。依司法院釋字第 140 號解釋之同一法理，應認該撤銷緩起訴處分自始無效，與緩起訴處分未經撤銷無異。則法院對該緩起訴處分案件，所提起之公訴，應視起訴時該緩起訴處分期間已否屆滿，而分別依刑事訴訟法第三百零三條第一款起訴之程序違背規定，或同條第四款緩起訴期滿未經撤銷，而違背同法第二百六十條之規定再行起訴，分別諭知不受理。

【閱卷委員的話】

1. 此次刑事訴訟法考題涉及偵查程序中之搜索扣押、撤銷緩起訴之程序、上訴利益及第三人參與沒收之適法性。首先，在閱卷過程中發現不少考生看錯題目，或是對題目有所誤解，導致答題方向有誤，建議考生仍應仔細閱讀題目，合理分配時間，切勿貪快而導致理解題目錯誤，反而得不償失。
2. 就第(一)子題的部分，應先區分為附隨於搜索之扣押，或是非附隨於搜索之扣押，並進行後續之作答。仍有不少考生無視題目「丙迅速扣押名牌包，隨後喚醒甲並予逮捕」之說明，在答題中書寫警察丙逮捕甲後，扣押名牌包，導致無法有理想之分數。
3. 第(二)子題的部分，涉及上訴利益之認定及第三人參與沒收之適法性，如能就爭點分別臚列，明確寫出實務及學說對此議題的看法，應能獲得較理想的分數。反之，如將數個爭點混合書寫，導致無法明確了解考生所欲處理的爭點，則可能無法獲得較佳之成績。
4. 第(三)子題的部分，為相對穩定之實務見解，有掌握到此實務見解與無法掌握之考生，呈現較大之落差，此外，此子題中有不少考生看錯題目，建議在較複雜的題型中，先將時間先後、人物關係先行釐清後再作答。